

1500779-81.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/07/2022

... conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, Nova Granada-SP - cep 15440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500779-81.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500779-81.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117209/2022 - DEL.POL.NOVA GRANADA, 24651446 -

DEL.POL.NOVA GRANADA, 2117209 - DEL.POL.NOVA GRANADA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

CLEBER RAFAEL DE LIMA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

CLÉBER RAFAEL DE LIMA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de abril de 2022, por volta das 03h40min, na Avenida Brasil, nº 1231, Bairro Jardim Mizael, nesta cidade e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico ilícito, trazia consigo 01 (um) frasco plástico transparente, fechado com tampa, contendo 07 porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 21,85g (vinte e um gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) e 01 (um) frasco plástico transparente, fechado com tampa, contendo 07 porções de cocaína na forma de 'crack', com peso líquido de 3,27g (três gramas e duzentos e setenta miligramas), substâncias essas proscritas conforme Portaria nº 344 ANVISA (Listas F1), consoante auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudos de constatação e

químico às fls. 72/75 e 163/165 respectivamente, conforme as circunstâncias narradas na denúncia.

Oferecida e recebida a denúncia (fls. 180/183 e 186/191), oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva decretada.

O réu foi pessoalmente citado, nomeada defensora (fls. 146) e apresentou resposta a acusação às fls. 235/238.

O pedido de absolvição sumária foi indeferido, mantida prisão preventiva e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 242/244).

Nesta audiência, foram inquiridas 02 (duas) testemunhas comum e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, em alegações finais, as partes fizeram suas postulações.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotografias das drogas e bens apreendidos (fls. 18/28 e 68), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 69/70), laudo de constatação (fls. 72/75), laudo do exame químico-toxicológico (fls. 163/165) e pelas demais provas colhidas no inquérito e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

Eis um resumo dos depoimentos colhidos nos autos.

Afonso Guimarães Prates Filho, Policial Militar, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina juntamente com seu companheiro quando avistaram o veículo que sabiam pertencer a pessoa de Cléber, conhecido como "Nino", com inúmeras denúncias de que seria traficante de drogas, além de suspeito de cometer diversos furtos. Se aproximaram do veículo e deram ordem parada. O réu, ao avistar a viatura, empreendeu fuga. Quando pararam o veículo perto da residência do acusado, o réu desceu e, antes de ser abordado, arremessou uma sacola plástica para o interior da sua residência. Foi realizada revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Encontraram a sacola plástica e, aberta, em seu interior foram encontrados um frasco pequeno com tampa amarela contendo em seu interior pedras da droga 'crack', um frasco pequeno com tampa cinza contendo invólucros plásticos contendo em seu interior mais droga 'crack' e um pedaço maior de droga 'crack'. No interior da carteira pessoal do acusado, foi encontrado uma cheque, dinheiro em notas diversas (todas eram notas miúdas) e uma folha contendo anotações alusivas a contabilidade do tráfico.

Fernando Christofolo, também Policial Militar, ratificou tudo o que o colega Afonso disse. Confirmou que ele e seu parceiro visualizaram o réu tentando dispensar entorpecentes quando saiu do veículo e que localizaram a substância, além de celulares, anotações de contabilidade e uma quantia em dinheiro no veículo. Confirmou ainda que o réu tentou evadir-se ao perceber a viatura e que o acusado é conhecido pela alcunha 'Nino', pessoa conhecida pelo envolvimento com drogas e furtos.

Em seu interrogatório, Cléber Rafael de Lima negou os fatos. Disse que é apenas usuário. No dia da abordagem, nada foi encontrado com ele. Apenas correu da polícia

porque estava sem carteira de motorista e o carro era emprestado. A contabilidade anexada aos autos diz respeito a serviços gerais praticados pelo acusado e das pessoas que deviam financeiramente a ele em decorrência de tais serviços. Narra que é perseguido pelos policiais devido a seu histórico criminal anterior.

Cabe salientar que os policiais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes. Deste modo, é necessário valorizar tais depoimentos pelo fato de que são agentes públicos que agem no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, calcados na boa-fé presumida, e, assim, são merecedores de toda a confiança, equiparados por qualquer indivíduo do corpo social há de merecer, até que o conjunto probatório confirme em contrário, inexistentes, outrossim, no caso em testilha

No caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que compromettesse a idoneidade da testemunha policial. Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995).

Nesse diapasão, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações”- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corrêu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corrêu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) - grifou-se.

Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação -Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato - (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos).

Ademais, a versão do réu restou isolada nos autos.

A distinção entre o tráfico e o porte deve ser feita à luz do § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A quantidade de entorpecentes apreendido e a maneira que estavam acondicionadas as drogas são fatores que militam contra o réu, já que foram apreendidas em seu poder 07 (sete) invólucros plásticos contendo 'crack', mais 07 (sete) invólucros plásticos contendo 'crack', pesando ao todo 25,10g (vinte e cinco gramas e dez miligramas), não havendo dúvidas quanto à intenção de revendê-la. Além disso, foram encontradas com o acusado notas pequenas e, não bastasse, uma folha relativa a contabilidade do tráfico (fls. 68), além de dois aparelhos celulares.

Embora o réu tenha alegado ser usuários de entorpecentes, referida circunstância, por si só, não tem o condão de descaracterizar o delito previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06 e de configurar o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pois, além da condição de usuário, o réu deveria ter provado que a droga encontrada em seu poder era destinada ao seu consumo pessoal, o que não foi feito, razão pela qual não há que se falar em desclassificação do delito a ele imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante - Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e

aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack - Tráfico de drogas consumado - Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas - Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes - condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria - Pena-base fundamentadamente exasperada - Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos).

Desse modo, tem-se que o Réu transportava, trazia consigo e/ou guardava drogas que se destinavam para consumo de terceiros.

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o réu CLÉBER RAFAEL DE LIMA, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou o fato descrito na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciarietade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No entanto, as provas foram suficientemente apresentadas e comprovam o teor da ilicitude através dos autos produzidos durante a fase policial e processual, quanto a quantidade do entorpecente e a forma de seu acondicionamento.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento que aponte que o acusado agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto aos autores, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Nos termos dos art. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, na primeira fase ressaltou que foi encontrado em poder do réu a droga 'crack', substância com alto poder destrutivo. Além disso, o réu consta com maus antecedentes (fls. 76/89), o que desautoriza a fixação da pena no mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, deve incidir a agravante da reincidência (fls. 76/78).

Majoro a pena em mais 1/6 (um sexto) restando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 porque ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 76-89), inexistindo outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena aplicada, diante da reincidência do Réu e da existência de maus antecedentes.

O réu também não faz jus à substituição da pena corporal pela restritiva de direito tampouco à concessão do sursis em face da reincidência e da quantidade de pena aplicada.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu CLÉBER RAFAEL DE LIMA, nascido aos 17/08/1984, filho de Jesus José de Lima e de Vera Lúcia Gouveia, pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar fixado.

O acusado encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa. Trata-se de providência acautelatória a fim de evitar a reiteração da delinquência e conferir credibilidade à justiça, motivo pelo qual o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se ao cárcere em que se encontra.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação do dano porque a questão não foi submetida ao contraditório.

Arcará o réu com as custas, cuja exigência fica sujeita ao disposto na Lei nº 1.060/50.

Considerando a demonstração de que o dinheiro apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

Considerando a demonstração de que o veículo apreendido (fl. 14) foi utilizado para o tráfico de drogas, sobretudo para o transporte das drogas apreendidas nestes autos, com fundamento no art. 91, II, "b", do Código Penal c/c art. 63, I, da Lei 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento do bem em favor da União. Anote-se que, embora o veículo esteja em nome de pessoa estranha à relação jurídico processual, o veículo foi apreendido na posse de um do réu. Some-se a isso o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). Ademais, "(...) A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Assim, havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes e, por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita(...)". AgRg nos EDcl no REsp. Deixo de aplicar detração porque inexistem outros elementos, como comportamento carcerário, a possibilitar a aplicação da benesse. Expeça-se certidão de honorários da patrona nomeada do réu (fls. 146).

Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, providências de praxe.

P.R.I.

Nova Granada, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA